

1500031-89.2022.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... pela desclassificação do crime de tráfico para a posse para consumo pessoal. Subsidiariamente, em caso de condenação por tráfico, requereu o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação de pena mínima, aplicação do regime inicial semiaberto, com a detração do período de prisão preventiva (fls. 184/194).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Em prefácio, observo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500031-89.2022.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500031-89.2022.8.26.0578

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DA SILVA ESTEVAO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

DANIEL DA SILVA ESTEVÃO, qualificado a fl. 06, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque segundo a denúncia na tarde de 07 de janeiro de 2022, por volta das 14 horas, na Rua Agostinho Ribeiro de Carvalho, 278, Vila Vista Alegre, nesta cidade e Comarca de Ourinhos/SP, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de consumo e comércio, 1,04 g de cocaína, na forma de dez pedras de crack, bem como 143,67 g da referida droga, na forma de oito pedras de crack, consoante se verifica pelo laudo de constatação provisória de fls. 15/17.

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa prévia (fls. 113/115).

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2022 pela decisão proferida às fls.

136/138, após o que o réu foi regularmente citado.

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e interrogado o réu, seguindo-se pela apresentação de alegações orais pela acusação, que pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da

imputação contida na denúncia (fls. 175/176 e 183 – gravação audiovisual). A Defesa, por seu turno, postulou em memoriais pelo reconhecimento de nulidade em decorrência do ingresso policial na residência do acusado e no mérito postulou pela desclassificação do crime de tráfico para a posse para consumo pessoal. Subsidiariamente, em caso de condenação por tráfico, requereu o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação de pena mínima, aplicação do regime inicial semiaberto, com a detração do período de prisão preventiva (fls. 184/194). É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Em prefácio, observo que a Defesa insurgiu-se em preliminar de mérito, sustentando nulidade processual em decorrência da ilegalidade do ingresso policial à residência do acusado, onde parte das drogas foram localizadas e apreendidas.

Com efeito, colhe-se dos autos que os policiais militares que compunham Equipe de Força Tática haviam recebido informação privilegiada dando conta que o denunciado estaria realizando o tráfico de drogas em seu endereço residencial, o que motivou a intensificação do patrulhamento naquela localidade, oportunidade em que os agentes públicos visualizaram o réu defronte ao imóvel residencial na companhia de terceiro indivíduo, os quais tentaram ingressar rapidamente na casa ao perceber a presença da viatura policial, levantando fundadas suspeitas da ilicitude em curso, que justificaram a rápida ação policial de abordagem, cuja revista pessoal do acusado resultou na apreensão de dez pinos contendo cocaína, prontos para a venda, configurando a situação flagrancial que por si apenas autorizaria o ingresso dos policiais no imóvel, na esteira do decidido no RHC 213852 AgR, de relatoria da i. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma do STF, publicado em 01/06/2022, in verbis: “A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado”.

Porém, para além disso, foi juntado aos autos gravação audiovisual da autorização dada pela esposa do acusado para os policiais ingressarem no imóvel, caindo por terra a alegação de que houve violação de domicílio pelos agentes públicos.

Ademais, destaco excerto extraído do Recurso Extraordinário nº 603.616/R0:

“Nada impede, contudo, que essas informações venham a dar base a pesquisas e, uma vez robustecidas por outros elementos, embasem a busca.

Logo, a tese é coerente com a jurisprudência acerca do lastro mínimo para medidas invasivas.

A solução preconizada não tem a pretensão de resolver todos os problemas. A locução fundadas razões demandará esforço de concretização e interpretação. Haverá casos em que o policial julgará que dispõe de indícios suficientes para a medida e o Juízo decidirá em contrário.

O fundamental é que se passa a ter a possibilidade de contestação de uma medida de busca e apreensão que deu resultados. Assegura-se à defesa a oportunidade de impugnar, em um processo contraditório, a existência e suficiência das razões para a medida. Ou seja, a validade da busca é testada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois.

A mudança cria espaço para formação de jurisprudência acerca dos limites da atuação policial, possibilitando o desenvolvimento e a concretização da garantia, a partir da avaliação jurisprudencial dos casos concretos.

Há também casos que apresentarão complexidades que ultrapassarão os limites do tema aqui apreciado.

Por exemplo, numa investigação sigilosa, pode surgir a notícia do crime permanente dentro de residência. No entanto, dar acesso ao dono da casa a todos os dados da investigação pode comprometer o restante das pesquisas. Em tese, poder-se-ia realizar investigação independente, documentando indícios mínimos para a busca e retendo o restante da prova. Os limites dessa prática, no entanto, não são aqui debatidos.

Também é comum que, no cumprimento de mandados de busca e apreensão, revelem-se situações de flagrante delito não previstas no objeto inicial. Numa busca por drogas, por exemplo, podem-se encontrar armas de uso proibido. Em princípio, o ingresso forçado está autorizado, pelo que não se cogita de vulneração da garantia da inviolabilidade de domicílio. No entanto, novamente, os limites da prática não

são aqui debatidos.

Tampouco se pretende aferir a validade de mandados de busca e apreensão coletivos. Esse expediente, que vem sendo usado em operações em favelas e comunidades conflagradas, testa os limites da garantia contra a inviolabilidade da casa de formas que não comportariam análise no presente tema.

Outra questão não apreciada é a validade do consentimento do morador. As hipóteses concretas podem revelar desdobramentos complexos, seja quanto à prova do consentimento, seja quanto a sua validade e suficiência. A Suprema Corte dos Estados Unidos vê com desconfiança o consentimento do morador obtido pelo agente estatal "sob autoridade governamental" (under government authority) ou "sob as cores do uniforme" (under color of office) – respectivamente, casos *Amos v. United States*, 255 U.S. 313 (1921) e caso *Johnson v. United States* 333 U.S. 10 (1948). Já houve algum debate sobre o assunto no HC 79.512, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 16.12.1999. O tema em julgamento, no entanto, não se presta a resolver a questão.

Enfim, há uma infinidade de complicadores que merecem avaliação em separado. Será a casuística que impulsionará o desenvolvimento de jurisprudência para enfrentar os diferentes temas".

Sob tal ângulo, necessário se ater ao que de concreto consta no caso sub judice, na qual se constata que o ingresso policial decorreu do conjunto de elementos fáticos que circundam a abordagem.

Não se olvide, ainda, que a legalidade da prisão em flagrante foi analisada oportunamente em juízo, quando restou homologada e determinou-se a conversão em preventiva, a qual foi reapreciada ao longo do trâmite processual, não se vislumbrando qualquer ilegalidade que permitisse a colocação do réu em liberdade. Por derradeiro, verifica-se que somente nesse avançado momento da marcha processual insurgiu-se a Defesa neste ponto, o que exsurge como mais um elemento a demonstrar a fragilidade do argumento aventado.

Com esteio nos fundamentos colimados, rejeito a preliminar, passando ao exame meritório.

Cuida-se de ação penal em que se imputa ao acusado o crime de tráfico de drogas, a qual merece procedência haja vista que o acervo probatório reunido nos autos corrobora a versão acusatória.

Isso porque, a materialidade encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 07/09 e 10/12; auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 15/17 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 148/152.

A autoria, por sua vez, decorre do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Por ocasião da lavratura da prisão em flagrante, o acusado Daniel da Silva Estevão, ao ser interrogado, informou que estava deitado no quarto e seu colega estava jogando vídeo game na sala. Neste momento, os policiais pularam o portão da casa, ingressaram no imóvel e "colocaram" o revólver no amigo do interrogando. Em seguida, os policiais também o ameaçaram utilizando uma arma. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram em seu poder dez pinos de crack que era destinado ao consumo do interrogando e do seu amigo. Além disso, os policiais encontraram R\$ 190,00 que era destinado ao pagamento do aluguel. Em seguida, os policiais ordenaram o acusado a sentar, tendo permanecido na sala, enquanto os policiais realizaram buscas no quintal de sua casa, tendo dito que encontraram mais entorpecentes. Negou que venda drogas. Afirmou ter feito o vídeo admitindo que os dez pinos de droga encontrados em sua posse lhe pertenciam.

Na esfera judicial, o réu admitiu novamente a propriedade das drogas, negando, no entanto, a destinação mercantil. Disse que todo entorpecente se destinava ao seu próprio consumo, acrescentando que na época dos fatos trabalhava no depósito de uma empresa ganhando R\$1500,00 e como vigia noturno ganhando R\$1800,00, bem como declarou fazer o consumo diário de drogas, chegando a consumir cerca de 20 gramas de crack por dia. Afirmou que o entorpecente encontrado no telhado da casa do vizinho lhe pertencia e estava escondido no local pois em sua casa não tem local para o armazenamento de drogas. Finalmente informou que os policiais invadiram sua casa,

sem mandado judicial.

Por sua vez, as testemunhas policiais militares Carlos Alexandre Cornélio e Murilo Colombo Nantes relataram no inquisitivo que após receberem informação de que o acusado, que seria membro de facção criminosa, estaria em sua residência fracionando e vendendo drogas, deslocaram-se ao endereço do mesmo, tendo a equipe visualizado Daniel e outro indivíduo de alcunha "Juca" na frente do imóvel, os quais ao visualizarem a viatura, tentaram entrar, contudo, foram abordados e submetidos à busca pessoal e com Daniel foram localizados R\$ 190,00 e dez pedras de crack embaladas individualmente prontas para a venda, já com "Jucá" havia R\$ 22,00. Na ocasião, o réu foi questionado se havia mais drogas em sua casa, o que negou. Ressaltaram a existência de informação privilegiada de que o acusado guardava drogas no forro da casa vizinha que está desabitada, sendo questionado a ele se teria drogas neste local, tendo o denunciado respondido: "perdi", afirmando que o restante da droga estaria no local mencionado. Diante disso, foi gravado vídeo, no qual o acusado permite que os policiais ingressem na sua casa, declarando que a droga encontrada é de sua propriedade. Além disso, a esposa do acusado, Tassiana, também autorizou a entrada dos militares no imóvel e da equipe do canil por meio de gravação audiovisual. Logo em seguida os cães farejaram o imóvel e mais nada de ilícito foi encontrado. Já no forro da casa vizinha lograram encontrar 8 (oito) pedras grandes de crack.

Durante a dilação probatória, o policial Murilo Colombo Nantes afirmou que na ocasião dos fatos estava participando de treinamento no Batalhão, oportunidade em que a equipe policial recebeu informação privilegiada de que o réu estaria em sua residência fracionando drogas. Acrescentou que a polícia militar já havia recebido informações em datas anteriores sobre a prática, pelo réu, do comércio ilícito de drogas em sua residência. Diante da informação recebida se deslocaram até o local e lá avistaram o réu e outro rapaz defronte ao imóvel, tendo eles tentado empreender fuga ao perceber a aproximação da equipe policial, no entanto acabaram sendo abordados e revistados, sendo com o réu, o qual é conhecido pela alcunha de Niel, dez porções de crack, além de dinheiro, o qual ele afirmou que era fruto de bicos realizados por ele. Na sequência os abordados foram algemados e questionados se havia mais entorpecentes na residência, tendo o réu negado. Informou que a informação que se tinha era que o réu guardava drogas no telhado do vizinho, razão pela qual o depoente subiu no muro da casa do réu e começou a olhar no telhado do vizinho, oportunidade em que avistou um pedaço do forro da casa que estava mais solto e ao vistoriar no local encontrou uma sacola que continha oito porções de crack, sendo seis delas tinham tamanho aproximado de 5 gramas e estavam acondicionadas em plástico ziplock, enquanto as outras duas porções eram de tamanho maior, sequer cabiam nas embalagens plásticas. Na oportunidade o réu confessou a propriedade do entorpecente e autorizou a realização de buscas na casa dele, no entanto nada de ilícito foi localizado no imóvel, somente foram encontradas embalagens plásticas do tipo ziplock. Acrescentou que a polícia militar também detinha informações privilegiadas, obtidas em abordagens policiais e com os vizinhos do réu, apontam que ele é membro de organização criminosa.

No mesmo sentido seguiram as declarações do policial Carlos Alexandre Cornélio, o qual relatou em juízo que na ocasião dos fatos estavam na prática de educação física quando recebeu informação de que o réu Daniel, conhecido pela alcunha de "irmão Niel", estaria traficando e picando drogas em sua residência, situada na rua Agostinho Ribeiro de Carvalho, n. 278, na Vila Nova, razão pela qual se deslocou até o local com seu colega de farda e, ao adentrarem a referida via avistaram o réu e a testemunha Juca defronte o imóvel residencial, oportunidade em que ele, ao notarem a presença da viatura policial, tentaram correr para dentro da casa mas foram alcançados, abordados e revistados, sendo que com Daniel foram encontradas 10 porções de crack, além da quantia de R\$190,00, cuja origem ele não esclareceu. Já com a testemunha Juca foi encontrada apenas a quantia de R\$29,00. Na oportunidade o réu foi questionado a respeito da existência de mais drogas em sua casa, o que foi negado, inclusive concordou que os policiais revistassem a casa com auxílio do cão policial. Do mesmo modo, a esposa do réu, que chegou no local na sequência, autorizou a entrada da equipe policial na casa, o que inclusive foi gravado com o

celular do depoente. Disse que enquanto aguardavam a chegada da equipe policial do canil, decidiram averiguar a informação privilegiada que dava conta que o réu armazenava drogas no telhado da casa do vizinho, ocasião em que acabaram localizado, no forro da casa vizinha, o restante do entorpecente apontado na exordial acusatória, cuja propriedade foi assumida pelo réu. Na sequência a equipe do canil chegou ao local e, com autorização do réu, realizou buscas no interior de sua casa, no entanto nada de ilícito foi localizado. Finalmente informou que há informações de que o acusado pertence à facção criminosa, inclusive num dos vídeos gravados no dia dos fatos o próprio réu admite que faz parte de organização criminosa.

Já a testemunha Hemerson Rafael Junior, cuja oitiva judicial foi dispensada, relatou no inquisitivo que possui apelido de Juca e que por ocasião dos fatos estava jogando vídeo game com o réu, os quais se encontravam sentados na sala da casa do acusado, tendo os policiais ingressado no imóvel sem autorização. Disse que os policiais revistaram o acusado e encontraram as drogas, oportunidade em que o réu alegou que era destinada ao consumo de ambos. Afirmou ser usuário de drogas, mas desconhecia que o denunciado vendia drogas. Não presenciou os entorpecentes localizados no imóvel vizinho.

Finalmente, a informante Tassiany Nascimento Rodrigues Pedro, cuja oitiva em juízo foi dispensada, declarou à D. Autoridade Policial que não tinha conhecimento de que o réu, que é seu marido, vendia drogas. Afirmou que não estava em casa quando os policiais chegaram. Ficou sabendo que os policiais já chegaram ingressando no imóvel, enquanto o réu estava deitado na cama. Quando chegou ao local ouviu o acusado dizendo que os policiais queriam forjá-lo. Não sabe dizer se as drogas encontradas no imóvel vizinho pertencem ao réu.

Estes são, em síntese, os elementos probatórios reunidos nos autos.

Como se vê, incontroversa a propriedade da droga apreendida na ocasião dos fatos, haja vista que o próprio réu admitiu tal fato nas duas oportunidades em que foi interrogado, o que restou corroborado pelos relatos dos policiais militares envolvidos na ocorrência, os quais, de forma harmônica e coesa, narraram que na ocasião dos fatos receberam informação privilegiada no sentido de que o réu estaria realizando o tráfico de drogas em sua residência e armazenando parte do entorpecente em um imóvel vizinho desabitado, razão pela qual se deslocaram até o local para averiguar a veracidade da denúncia, sendo que lá se depararam com o réu e outro rapaz defronte ao imóvel residencial, os quais, ao notarem a presença da equipe policial, tentaram evitar a abordagem correndo para dentro da casa, no entanto foram rapidamente alcançados, abordados e revistados, o que resultou na apreensão, na posse do réu, de dez pinos contendo cocaína e o valor de R\$ 190,00. Diante do contexto flagrancial, foram realizadas buscas no imóvel e mais nada de ilícito foi encontrado, porém confirmando o teor das denúncias recebidas, foram localizadas escondidas no forro do telhado do imóvel vizinho mais pedras brutas do mesmo entorpecente, cuja propriedade foi assumida pelo denunciado.

O debate central cinge-se, portanto, quanto à destinação das drogas, se para o consumo pessoal, como sustentou o réu em sua defesa pessoal, ou se para consumo de terceiros, conforme sustentado pela acusação.

Nesse sentido, importante ressaltar que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal.

Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova.

No caso dos autos, foram apreendidas 143,67 gramas de cocaína, na forma do subproduto crack, em porções brutas, quantidade expressiva, que indica o propósito comercial tendo em vista que o cotidiano forense tem demonstrado que cada porção do referido entorpecente pesa em torno de 0,1 grama.

Além disso, ocorreu a apreensão de 1,04 gramas do mesmo entorpecente, dividido em dez porções individuais, circunstância que constitui forte indício da traficância porquanto o prévio fracionamento facilita o comércio a terceiros. Neste sentido: "Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo,

sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - rel. ENÉAS MACHADO COTTA, RDTJRJ 23/288).

"Identificando o fornecedor das substâncias tóxicas, em poder de quem foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, parte já dividida em dezenas de papelotes, prontos para entrega a consumo, impõe-se a condenação por tráfico, sem que se possa, todavia, reconhecer associação com compradores" (TJRJ - rel. PAULO GOMES DA SILVA FILHO, RDTJRJ 20/313).

Soma-se a estes indícios que, além do entorpecente, foi apreendida a quantia de R\$ 190,00 (cento e noventa reais) em dinheiro na posse do acusado, cuja origem deste valor não restou suficientemente esclarecida, sendo possível concluir, diante do contexto dos autos, que o montante foi obtido através da venda de drogas.

Cabe anotar ainda que o acusado ostenta uma condenação pela prática da traficância, que caracteriza a reincidência específica, conforme aponta a certidão de fls.

37/38, revelando que já vem se dedicando ao tráfico há algum tempo, circunstância que analisada "em conjunto com os demais critérios de aferição do consumo pessoal, os antecedentes do acusado podem ser sopesados pelo magistrado para o correto enquadramento típico, sem que se possa objetar que isso caracterizaria um retorno indevido ao Direito Penal do autor" (Renato Brasileiro de Lima, em Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2014, p. 696).

Ademais, não se pode esquecer que a apreensão dos entorpecentes e do valor em dinheiro não se deu ao mero acaso, mas foi precedida por informações privilegiadas que chegaram ao conhecimento da equipe de Força Tática da Polícia Militar, que patrulhando os arredores do endereço do acusado, visualizou-o defronte a residência com outro indivíduo, os quais tentaram ingressar rapidamente para o interior do imóvel ao se depararem com a viatura, ocorrendo a rápida ação policial, que resultou na apreensão das drogas na posse do acusado e também no imóvel vizinho, tal qual relatado na delação recebida.

Neste ponto, vale salientar que não se vislumbrou, em qualquer momento do processado, fatos que pudessem colocar em dúvida a ação policial, ou mesmo desabonassem os depoimentos prestados por essas testemunhas.

Demais disso, é pacífico o entendimento de que os depoimentos dos policiais devem ter o mesmo valor probante que os de qualquer outra testemunha compromissada, mormente quando harmônicos com as demais provas amealhadas aos autos. Nesse sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age acionamento ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos [...]"(HC n. 74.608-0, rel. Minc Celso de Mello)

Nesse sentido também destaca decisão de lavra da Corte Bandeirante:

"Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJSP; Apelação Criminal 0013199-80.2013.8.26.0278; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 11/06/2018).

Em oposição a esse farto contexto probatório, nota-se a fragilidade da defesa pessoal do réu, o qual sustentou ser usuário de drogas, porém não logrou êxito em comprovar aferir rendimento suficiente para financiar o vício declarado.

Ademais, a simples declaração de ser usuário de drogas não descaracteriza a traficância. Tal fato, por si só, não implica na pretendida desclassificação, posto ser extremamente comum na atualidade a figura do “viciado-traficante”, aquele que, além de fazer uso de drogas, a comercializa para manter o próprio vício, exatamente o que parece ser o caso do réu.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para demonstrar a responsabilidade criminal do réu quanto ao crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Portanto, presentes a tipicidade, ilicitude e culpabilidade do réu deve ser condenado e submetido ao cumprimento da lei penal, por ser medida de justiça. Não havendo qualquer outra consideração a ser feita, passo a dosimetria e à fixação da pena, atenta às diretrizes fixadas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Nessa esteira, verifico que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, é ínsita ao tipo penal. O réu registra condenação anterior (fls. 37/38), a qual será considerada na próxima etapa como circunstância agravante e, por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para análise de sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias e as consequências do crime devem ser analisadas nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06. O crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva em apreço, cuja natureza do entorpecente apreendido, cocaína, na forma do subproduto crack – de alto poder nocivo à saúde humana – deve elevar a pena base, a qual fixo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes. Lado outro, incide a agravante da reincidência, que é específica, conforme fls. 37/38. Aqui, cediço que o Código Penal não estabelece limite mínimo e máximo para o aumento da reprimenda em casos de circunstâncias agravantes.

Por outro lado, esta julgadora não se escusa do entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há diferenciação entre a reincidência específica ou genérica no tocante à fração a ser aplicada em decorrência desta agravante, havendo consenso do montante de um sexto seja qual for a hipótese. Todavia, no caso em apreço estão presentes circunstâncias concretas que determinam o maior agravamento. De acordo com a folha de antecedentes de fls. 37, observa-se que o denunciado sequer havia cumprido integralmente a condenação anterior e tornou a incidir na mesma conduta, tornando maior o grau de reprovabilidade da conduta. Além disso, referido entendimento encontra eco em julgados proferidos pela Corte Bandeirante. Vejamos:

“Reincidente específico em relação ao tráfico de drogas, daí porque justificável o aumento na fração de 1/4, dada a maior reprovabilidade” (TJSP; Apelação Criminal 1501900-52.2019.8.26.0559; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

“Em que pese a lei não defina o percentual a ser adotado, esta Câmara vem reiteradamente optando por 1/5” (TJSP; Apelação Criminal 1502791-90.2020.8.26.0542; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Destarte, tendo como norte os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, agravo em 1/5 (um quinto) a pena anteriormente fixada, a qual passa ao montante 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a qual torno concreta na ausência de outros elementos que possam modifica-la.

Finalmente, tratando-se de réu reincidente específico, inviável a aplicação do benefício disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006. Neste sentido, “Na etapa derradeira, impossível o acolhimento da pretensão da defesa, tendo em vista a reincidência do paciente, a qual afasta a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (HC 395.081/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso em apreço, trata-se de réu reincidente específico (artigo 44, inciso II, §

3º, do CP) e foi condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, (artigo 44, caput, CP), o que afasta a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de crime hediondo, a lei impõe a fixação no fechado. Porém, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Nesses termos, observa-se que o réu encontra-se encarcerado preventivamente desde a data do flagrante, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, conforme art. 112, inciso VII, da Lei nº. 8.072/90, com redação dada pela Lei nº. 13.964/19. Logo, fixo, para ele, o regime inicial FECHADO.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra DANIEL DA SILVA ESTEVÃO, qualificado a fl. 06, para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O réu deve permanecer encarcerado, posto que, através da presente decisão, foi reconhecida a sua responsabilidade pelo crime de tráfico de drogas, mola propulsora de tantos outros delitos que causam desordenada delinquência na sociedade, sendo responsável por sustentar o crime organizado.

Ademais, trata-se de réu reincidente específico, e com mais uma condenação por delito da mesma natureza ainda pendente de cumprimento de pena, evidencia concreta de que pode reiterar na prática delitativa, como se vê às fls. 37/38. Esses elementos denotam profundo envolvimento com práticas ilícitas e a persistência na conduta em questão apesar do esforço estatal para ressocializá-lo.

Não se deslembra, ainda, que fora fixado o regime fechado para o cumprimento inicial de pena, o que, por si só, é incompatível com o estado libertatis. Deve ser levado em consideração, igualmente, a inexistência de previsibilidade de libertação breve, haja vista a recente modificação trazida pela Lei nº. 13.964/19 recrudescer as frações para obtenção da progressão de regime. Dessa forma, a manutenção ao cárcere também se mostra imprescindível para garantia da aplicação da lei penal, notadamente considerando a reprimenda efetivamente aplicada ao sentenciado.

Portanto, há, concretamente, a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar decretado outrora com base em elementos indiciários que foram confirmados por meio da análise do *meritum causae*. Em situações semelhantes, a Corte Paulista assim reconheceu:

"Habeas Corpus - Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico - Prolação de r. sentença - Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos requisitos da custódia cautelar - R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada - Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas - declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum - decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência - Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2249810-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020) destaquei.

Ante o exposto, o réu não poderá aguardar o resultado de eventual recurso em liberdade. Recomende-se-lhe, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal; b) proceda-se a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, seguindo-se as instruções baixadas pelo Ministério da Justiça para esse fim.

De acordo com o que dos autos consta, deixo de condená-lo(a)(s) às custas processuais.

Expeça-se certidão de honorários oportunamente.

P.I.C.

Ourinhos, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA